

<제5편 병합소송.제11장 병합청구소송.제01절 청구의 원시적 병합>

[기출][2022-1-1]예비적 병합에서 일부 판결의 적법성 및 누락된 청구에 대한 불복방법

《[문제1] 동업관계에 있는 乙, 丙, 丁, 戊는 자신들의 사업장 앞에 있는 X토지를 甲으로부터 임차하여 주차장으로 사용하고 있었다. 위 4인을 대표한다고 주장하는 乙은 X토지를 甲으로부터 매수하기로 하고 甲과 X토지에 대한 매매계약을 체결하였다. 사업자금의 대출을 위해 X토지의 등기가 필요하다는 사정을 들은 甲은 매매대금의 전액을 지급받지 못하였음에도 불구하고 X토지의 등기를 위 4인에게 이전하여 주었으나 위 4인은 매매잔대금을 지급하지 않고 있다. 이에 甲은 乙, 丙, 丁, 戊를 상대로 주위적으로는 매매계약이 유효하다면 X토지의 매매대금 전액의 지급을 구하고, 예비적으로는 매매계약이 무효라면 X토지의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. (단, 아래의 각 물음은 독립적임) (50점)

(물음1) 제1심 법원은 乙에게 적합한 대리권이 없었다는 것을 이유로 원고의 주위적 청구를 배척하면서도 예비적 청구에 대하여는 아무런 판단을 하지 않았다. 이러한 제1심 법원의 판결에 대해 적법 여부와 불복방법에 관하여 쓰시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 예비적 병합에서 일부 판결의 적법성 및 누락된 청구에 대한 불복방법

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙, 丙, 丁, 戊를 상대로 매매대금 지급을 구하는 주위적 청구와 소유권이전등기 말소를 구하는 예비적 청구를 병합하여 제기하였으나 제1심 법원이 주위적 청구만 배척하고 예비적 청구에 대한 판단을 누락한 상황이다. 쟁점으로 <법원이 예비적 청구에 대한 판단을 하지 않은 경우의 판결의 적법성과 이에 대한 당사자의 불복방법>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 예비적 병합청구에서 판단누락의 효력과 이를 시정하기 위한 상소방법을 설명한다.

II. 예비적 병합의 심판법리와 재판의 유탈

1. 일부판결의 허용 여부

(1) 예비적 병합의 심판원칙

- 예비적 병합이란 원고가 양립할 수 없는 수개의 청구를 제기하면서 주위적 청구가 기각되거나 인용되지 않을 것을 해제조건으로 하여 예비적 청구의 심판을 구하는 소송 형태이다. 수소법원은 원고가 정한 심판 순위에 전적으로 구속되므로, 반드시 주위적 청구를 먼저 심리·판단하여야 한다.

(2) 절차적 불가분성과 일부판결 금지

- 예비적 병합은 각 청구가 조건부로 결부되어 있어 절차적으로 분리될 수 없는 불가분적 성질을 지닌다. 따라서 수개의 청구를 분리하여 변론하거나 일부판결을 선고하는 것은 소송법상 허용되지 않는다.

2. 판단 유탈의 법적 성질

(1) 학설의 대립

- 주위적 청구를 기각하면서 예비적 청구 판단을 빠뜨린 경우에 대하여 견해가 대립한다. ❶ 재판누락설은 이를 "민사소송법 제212조"의 재판의 누락으로 보아 누락된 부분이 여전히 원심에 계속되어 있으므로 추가판결을 구해야 한다는 견해이다. ❷ 판단누락설은 일부판결을 할 수 없는 경우에 해당하여 하자가 있는 전부판결로서 판단의 누락에 해당하고 상소로 다루어야 한다는 견해이다.

(2) 판례의 태도

- "대법원 전원합의체 판결"은 판단누락설의 입장이다. 예비적 병합에서는 일부판결이 허용되지 않으므로, 주위적 청구를 기각하면서 예비적 청구에 대한 판단을 누락한 판결은 형식적으로 전부판결로 취급되며, 이는 판결의 내용상 흠결인 판단의 누락에 해당한다고 판단하였다.

III. 사안의 적용

1. 제1심 판결의 적법 여부 검토

(1) 심판의무의 위배

- 원고 甲이 임차 및 매매계약과 관련하여 제기한 주위적 청구(매매대금 청구)와 예비적 청구(이전등기말소 청구)는 계약의 유효·무효를 전제로 하므로 양립 불가능한 예비적 병합 관계이다. 제1심 법원이 乙의 대리권 결여를 이유로 주위적 청구를 배척하였다면, 조건 성취로 인해 예비적 청구를 판단하여야 할 심판의무가 당연히 발생한다.

(2) 일부판결 위법의 존재

- 그럼에도 제1심 법원이 주위적 청구에 대해서만 기각 판결을 선고하고 예비적 청구에 대해 판단하지 않은 것은 일부판결을 전면 금지하는 예비적 병합의 심판법리를 정면으로 위반한 위법이 존재하므로 부적법하다.

2. 원고 甲의 적법한 불복방법

(1) 추가판결 신청의 불가능

- "판례"의 판단누락설에 의하면, 제1심의 부적법한 판결은 재판의 누락이 아닌 전부판결에서의 판단의 누락에 해당하므로 제1심의 소송계속은 종료된다. 따라서 원고 甲은 제1심 법원에 대하여 "민사소송법 제212조"에 따른 추가판결을 청구할 수 없다.

(2) 항소 제기를 통한 구제

- 원고 甲은 제1심의 위법한 판결 전부에 대하여 적법하게 항소를 제기하여야 한다. 이 경우 항소제기에 따른 이심의 효력에 의해 주위적 청구뿐만 아니라 판단이 누락된 예비적 청구까지 청구 전부에 대하여 항소심으로 이심된다. 항소심 법원은 제1심의 위법을 시정하기 위해 누락된 예비적 청구까지 심판 범위에 포함하여 판단하여야 한다.

IV. 결론

- 법원이 주위적 청구를 기각하면서 예비적 청구에 대하여 아무런 판단을 하지 않은 판결은 일부판결을 할 수 없는 예비적 병합의 소송법적 대원칙을 무시하여 내린 판결로서 위법하며 부적법하다. 해당 판결은 판단의 누락에 해당하므로 원고 甲은 추가판결을 신청할 수 없으며, 제1심 판결에 대하여 적법하게 항소를 제기함으로써 사건 전체를 항소심으로 이심시켜 유탈된 예비적 청구에 대한 올바른 판결을 받아야 한다.